

1501041-73.2021.8.26.0621
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/06/2022
... do E. Tribunal de Justiça:

"Apelações - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - (...) - Mérito - Mantida a condenação dos corréus pelo crime de tráfico de drogas - (...) - Incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Crime praticado nas imediações de praça pública, recinto onde se realizam "diversões de qualquer natureza" - (...) - Apelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501041-73.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501041-73.2021.8.26.0621
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2325837/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 21695379 - 2º Distrito Policial de Lorena, 1153/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2325837 - 02º D.P. LORENA, 1153/21/204 - 02º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS VALIM
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS VALIM, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na peça inicial de fls. 119/121.

Oferecida a denúncia, o réu apresentou a sua defesa prévia (fls. 72/73). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 15/03/2022, agendando-se a audiência de instrução e julgamento (fls. 91/95).

No curso da instrução foram ouvidas a testemunha e a informante judicial, sendo o réu interrogado, ao final. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais em audiência (mídia às fls. 135).

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a fixação da base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado; e o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei em assunto, sob o argumento de que as praças públicas não constam daquele rol, o que seria analogia in malam partem. Alegou também que os maus antecedentes não devem ser considerados, à vista dos indultos que foram concedidos ao réu, o lapso temporal decorrido após a condenação.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fl. 09), fotografias (fl. 18), laudo de constatação provisória (fls. 19/21) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 59/61), cujos resultados foram positivos para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; bem como as provas orais existentes nos autos.

A prova de autoria também é certa, começando pelo estado flagrancial. Senão vejamos.

O policial militar Lincoln Monteiro Bustamante Sá contou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando observou o réu mexendo na grama em uma praça. Afirmou que este, ao ver a aproximação da viatura policial, tentou evadir-se, porém, foi alcançado e abordado. Disse que o réu admitiu que traficava no local. De acordo com o depoente, na posse de Mateus nada de ilícito foi encontrado, contudo, em diligências junto ao lugar onde este fora visto mexendo, entorpecentes foram encontrados. Questionado, disse que o réu já havia sido abordado anteriormente pelo mesmo motivo, porém, em tal ocasião nada foi achado de ilícito. Indagado, disse que a praça onde os fatos se passaram é utilizada por traficantes para a venda de drogas.

Já a genitora do acusado, Maria José dos Santos Valim, afirmou que o filho estava com sua saúde debilitada, por diversos motivos. Afirmou que Mateus é usuário de drogas. Disse que seu filho possui problemas mentais herdados de sua família paterna, e que a dependência química agrava tal condição.

Por sua vez, o réu declarou inocência em seu interrogatório. Contou que estava no local para adquirir entorpecentes, e que havia acabado de comprar sete "capinhas" (pinos de "cocaína"), quando os policiais militares o abordaram. Negou ter tentado fugir. Afirmou que os agentes da lei apresentaram quatorze "capinhas" na delegacia, reconhecendo a propriedade apenas de sete delas, as quais consumiria. Disse que assinou seu termo de interrogatório policial sem ler. Questionado, disse que à época encontrava-se desempregado, com duas pensões alimentícias atrasadas, além de enfrentar problemas de saúde. Declarou que no dia dos fatos estava sob efeito de drogas..

Esse é o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, é incontroverso que o réu possuía ao menos parte dos entorpecentes apreendidos, vez que assim admitiu sob o crivo do contraditório.

Contudo, sustenta o acusado que tais drogas serviriam ao seu próprio consumo.

Logo, o ponto nodal do processo é desvendar o destino que ele daria aos entorpecentes: se os venderia, ou os consumiria.

Na hipótese dos autos, ponderando sobre as circunstâncias do caso concreto, entendo que a prova acusatória aqui formada é suficiente para se concluir que as drogas (ou parte delas, ao menos) tinham a finalidade mercantil.

Neste ponto, insta registrar, tal como já sustentado em outras oportunidades, que costume conferir ampla credibilidade às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a

testemunharemos sobre o que realmente viramos sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisor o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço é mais um dentre outros tantos no qual o réu tenta, em vão, desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova do que alega, procurando assumir conduta menos grave.

Não se olvide ainda que em seu interrogatório policial, ato em que se fez acompanhar por advogado constituído, o réu admitiu a realização da mercancia maligna no local (fls. 04/05).

Portanto, forçoso reconhecer que o acusado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de estratagemma criada para incriminá-lo, deixando de apontar motivo sério que permitisse tal conclusão, diante da ausência de qualquer elemento nesse sentido, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Destarte, encampar a versão defensiva, apenas confiando na palavra do réu, sem o mínimo lastro probatório, seria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, diante do farto conjunto de provas pela sua condenação, até mesmo sua própria confissão em sede policial, como também desprestigiar as declarações da testemunha policial.

Lado outro, o fato de eventualmente Mateus ser usuário de drogas, de modo algum, o impede de também vendê-las. Muito pelo contrário, pois não raro usuários passam a assim agir, a fim de financiarem a própria dependência, o que parece ser o caso dos autos.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

“Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos”. (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

“Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Outrossim, desnecessário para a caracterização do crime de tráfico de drogas que o agente seja flagrado em atos de mercancia, uma vez praticada uma das outras inúmeras ações previstas no tipo penal, esclarecendo-se que a finalidade mercantil deve ser demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, tal como acima fundamentado.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas –

Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Por fim, com relação à causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, de natureza objetiva, conforme jurisprudência consolidada nesse sentido (AgRg no HC 715063/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data do julgamento 03/05/2022, Data da publicação 10/05/2022), restou provado nos autos que o réu estava escondendo as drogas, para vendê-las em praça pública, local onde se realiza "diversões de qualquer natureza", nos termos da lei. Logo, ao contrário do sustentado pela defesa, não se pode cogitar em analogia in malam partem para se reconhecer tal majorante.

Nesse sentido o entendimento recente do E. Tribunal de Justiça:

"Apelações - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - (...) - Mérito - Mantida a condenação dos corréus pelo crime de tráfico de drogas - (...) - Incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Crime praticado nas imediações de praça pública, recinto onde se realizam "diversões de qualquer natureza" - (...) - Apelos defensivos não providos e apelo ministerial parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500166-31.2020.8.26.0333; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Macatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - (...) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO DE DROGAS QUE OCORRIA EM PRAÇA PÚBLICA - Impossibilidade. Verificado que a prática do tráfico ocorria em praça pública, local notadamente destinado a diversões de qualquer natureza, onde é comum a prática de atividades sociais, culturais e recreativas, inviável o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1501788-08.2019.8.26.0196; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020) (Ênfase nas reproduções).

Portanto, o caso é de condenação, nos exatos termos da exordial acusatória.

Passo à calibragem penal.

Na primeira fase, verifico que a quantidade de drogas apreendida (20,10 gramas, massa bruta, de "cocaína", divididos em 14 pinos plásticos), embora suficiente para comprovar a conduta, não excede ao tipo penal.

Contudo, atento à certidão de fls. 139/141, verifico que o réu possui duas condenações com trânsito em julgado, configuradoras de maus antecedentes.

Ao contrário do argumentado pela defesa, os Tribunais Superiores já fixaram o entendimento que o decurso do tempo não é suficiente para apagar tais registros desabonadores, ao passo que o indulto não retira os efeitos secundários das condenações definitivas.

Confira-se o Tema 150, do Supremo Tribunal Federal - STF, cuja ementa transcrevo abaixo, e a Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes

condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (STF; RE 593818; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 18/08/2020; Publicação: 23/11/2020) (Sublinhado meu); e

Súmula 631, do STJ: "O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais".

Logo, à vista dos seus maus antecedentes, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Na fase intermediária, as sanções permanecem inalteradas.

Deixei de reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, vez que o réu, como se viu, negou sua responsabilidade penal pelos fatos aqui julgados, assumindo conduta menos gravosa, como forma de se ver livre da acusação que lhe foi direcionada.

Nesse sentido:

"Ação Penal - (...) - Sentença condenatória - (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea - Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias - Caracterização de 'confissão qualificada' pelo magistrado, que não admite a redução da pena - Inexistência de confissão para este Relator - (...) - Regime fechado - Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão". (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

Na terceira e última fase, tal como já fundamentado acima, incide à espécie a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), para fixá-la em definitivo em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à míngua de outras causas alteradoras.

Inaplicável o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, por conta dos maus antecedentes do acusado, requisito expresso no texto legal.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

"Embargos de declaração - (...) - Novo entendimento do STF em relação aos maus antecedentes em sede de repercussão geral - Possibilidade de se considerar, para tais fins, condenação cuja punibilidade esteja extinta há mais de cinco anos - Os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado - (...) - Regime inicial alterado para o fechado, diante da quantidade de pena imposta e dos maus antecedentes". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500561-12.2019.8.26.0542; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de

Registro: 19/10/2020) (Sublinhado meu).

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, em razão do C. Supremo Tribunal Federal – STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que tal precedente não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, à vista dos maus antecedentes do réu, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS VALIM, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da ambos Lei 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado; bem como o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, diária mínima.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras, à luz do montante aplicado da pena aplicado, ou mesmo da natureza equiparada à hedionda do delito, ora em tela.

Nego, outrossim, o apelo em liberdade para esse acusado. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva desse implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual, em especial, de acusado que ostenta passado criminal desabonador.

Ademais, não faz qualquer sentido soltar o réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, agora, depois de condenado.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também garantir a ordem pública, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista – Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

No entanto, havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

A propósito:

"APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – (...) Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não caracterizada no caso em comento, uma vez que os apelantes possuem advogados constituídos nos autos – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502659-13.2021.8.26.0408; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (Ênfase minha).

A autoridade policial já está ciente da determinação para destruição dos entorpecentes apreendidos (fls. 81).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA